

포괄임금제의 쟁점과 전망*

심 재 진**

목 차

- I. 서론
- II. 해석론
- III. 규제론
- IV. 결론

I. 서론

포괄임금제에 대한 규제는 문재인 정부의 100대 국정 과제 중 71번째인 ‘휴식있는 삶을 위한 일·생활의 균형 실현’의 일부로 포함되어 있다.¹⁾ 이 과제를 구체적으로 보면 연간 1800시간대로의 노동시간 단축을 목표를 달성하기 위한 정책방안을 제시한다. 그것은 주52시간 근로 확립, 장시간 근로사업장 지도·감독 강화, 근로시간 특례 제외 업종 및 4인 이하 사업장 개선방안 마련 등이다. 이러한 방안의 하나로 포괄임금제 규제가 명시되어 있다.

이러한 점들을 감안하면 현재의 정부는 장시간 근무 제한의 맥락에서

투고일 2017. 11. 20, 심사일 2017. 12. 3, 게재확정일 2017. 12. 10.

* 이 논문은 필자가 동일한 제목으로 한국노동법학회·노동법이론실무학회 공동 학술대회 『임금 및 근로시간법제의 쟁점과 과제』(2017.9.23.)에 발표한 것을 수정하고 보완한 것이다.

** 서강대학교 법학전문대학원 부교수.

1) 국정기획자문위원회, “문재인정부 국정운영 5개년 계획”, 2017년 7월, 107면.

포괄임금제 규제를 추진하고 있음을 알 수 있다. 하지만 현재까지 포괄임금제를 구체적으로 어떻게 규제할 것인지에 대해서는 정부가 공식적으로 밝힌 바는 없다. 이러한 규제를 위해 현행 판례법리에 바탕을 두고 근로감독을 강화하는 것²⁾이나 금지업종을 명시하는 입법을 추진하는 것 등이 검토되고 있는 것으로 보인다.³⁾ 현 정부가 현재의 상황상 입법까지는 추진하지 않을 것이라고 예측하기도 한다.⁴⁾

포괄임금제가 법원에서 문제가 되는 것은 포괄임금제로 인하여 연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대한 수당이 법에서 정한 기준에 미달하게 지급되었다는 주장 때문이다. 민사적으로 포괄임금제는 원고인 근로자의 임금청구에 대해 사용자가 “포괄임금제에 의한 임금지급계약이 체결되어 원고 주장의 미지급 법정제수당은 그에 따라 포괄적으로 지급된 임금 중에 포함되어 전액 지급하였으므로 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장하는 분쟁사례”로 주로 발생한다.⁵⁾ 포괄임금제와 관련한 대부분의 판결은 민사상의 임금지급청구소송에 대한 것이다. 그렇지만 형사적으로도 포괄임금제는 다루어진다. 형사적으로는 사용자가 임금미지급으로 기소된 사안에서, 사용자가 미지급 법정제수당이 그에 따라 포괄적으로 지급된 임금 중에 포함되어 전액 지급하였으므로 유죄가 아니라고 주장하는 것으로 드러난다.⁶⁾

이 글은 포괄임금제에 대해 해석론과 입법론 모두를 다룬다. 이 글은 일차적으로는 포괄임금제와 관련하여 해석론과 입법론상의 주요 쟁점들을 분석하고 정리한다. 이 과정에서 해석론과 입법론을 총괄하여 포괄임금제에 대해 어떠한 방식의 규제가 바람직한지에 대해 시사점을 도출해 보고자 한다.

2) 도재형, “포괄임금제 금지 공약에 더해”, 한국일보, 2017.5.7. 칼럼 참조.

3) “야근 부추기는 포괄임금제 없앤다”, 서울경제신문, 2017.8.29.

4) 신용간, “포괄임금제에 대한 새 정부의 정책방향과 기업의 대응방안”, 『노동법률』 2017년 9월호, 81쪽.

5) 김지형, “노동쟁송과 판례연구(하)”, 『인권과 정의』 제319호, 대한변호사협회, 2003.

6) 최근의 대법원 판결은 형사사건이 많다. 대법원 2014.6.26. 선고 2011도12114 판결, 대법원 2016.9.8. 선고 2014도8873 판결, 대법원 2016.10.13. 선고 2016도1060 판결은 모두 형사사건들이다.

포괄임금제의 성격, 적용대상, 정산가능여부 등을 둘러싸고 견해가 대립되고 있다. 포괄임금제의 성격과 관련해서는 예외성 인정설/예외성 부정설, 적용대상에 대해서는 엄격해석론/확대해석론, 정산가능여부에 대해서는 정산가능설/불능설로 견해가 나뉜다.⁷⁾ 포괄임금제의 특정 측면에서 견해가 나뉘는 것이나 근로시간의 산정이 힘든 경우에 포괄임금제가 유효하다고 보는 점과 근로시간의 산정이 가능한 경우에 근로기준법 등이 정한 최저기준에 미달하는 경우 유효하지 않다고 보는 점에서 이들 견해들은 일치한다.⁸⁾ 단지 이것을 설명하는 방식의 차이가 있을 뿐이다. 이 점을 고려해 이 글에서는 포괄임금제와 관련한 앞의 견해 차이를 별도로 다루지 않기로 한다.

II. 해석론

1. 대법원 판례법리의 변화

대법원의 이전 판결에서는 성립유무에 대한 판단과 유효성 여부에 대한 판단의 구별이 명료하지 않았다. 예를 들어 서울지하철의 청원경찰의 포괄임금제에 대해 성립여부의 사실관계와 유효성 여부의 사실관계를 함께 나열한 후, “포괄임금계약이 체결되었다 할 것이고 위의 포괄임금계약을 무효라고 할 수도 없다”고 대법원은 1997년에 판시하였다.⁹⁾ 또한 2002년 아파트 경비원에 대한 사건에서 대법원은 “포괄임금제에 의한 임금계약이 체결되었다면 원고가 포괄임금으로 지급받은 연장근로수당 또는 이에 갈음한 시간외수당, 야간수당, 휴일수당 등에는 근로기준법의 규정에 의한 시간외근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당이 모두 포함되어

7) 이러한 견해 차이의 설명에 대해서는 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 『인권과 정의』 제347호, 대한변호사협회, 2005; 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 『노동법학』 제29호, 한국노동법학회, 2009, 331쪽 이하 참조.

8) 정재현, “포괄임금제의 재조명”, 『사법』 제15호, 사법발전재단, 2011, 96쪽.

9) 대법원 1997.4.25. 선고 95다4056 판결.

있다”고 보아 차액의 지급을 명한 것이 포괄임금제 법리에 맞지 않다고 판시하였다.¹⁰⁾ 이러한 판시는 별도의 유효성 여부에 대한 판단 없이도 포괄임금계약이 성립되었으면 유효하다고 판단하는 것이어서 유효성 여부에 대한 독자적인 판단이 없는 셈이다.

이러한 상황에서 2009년과 2010년에 각각 내려진 두 개의 대법원 판결을 기점으로 포괄임금제에 대한 판례법리의 판단방식에 변화가 이루어지기 시작하였다. 2009년의 대법원 판결(이하 2009년 판결)¹¹⁾은 포괄임금제의 성립에 대해서, 2010년 대법원 판결(이하 2010년 판결)¹²⁾은 포괄임금제의 유효성에 대해 각각 다루었다. 이 판례들을 기점으로 판례법리는 포괄임금제의 성립 유무와 성립된 포괄임금제의 유효성을 구별하여 판단하였다. 학설에서는 일찍이 기존의 판례법리를 성립여부에 대한 부분과 유효성에 관한 부분을 항목을 달리하면서 구별하여 설명한 견해가 있었다.¹³⁾ 그러나 포괄임금제가 성립하는 경우 원고 주장의 미지급 법정제수당 청구를 배척하게 된다고 설명하여, 양자의 관계를 현재와 같은 방식으로 파악하는 데까지는 나아가지 않았다.¹⁴⁾

포괄임금제 성립 여부와 유효성을 구별하는 것은 포괄임금제의 유효성을 판단하기 위해서는 포괄임금제 약정 자체가 있는 것을 전제로 하여야 한다는 점에서 논리적이다. 포괄임금제 약정이 성립되지 않는다면, 이를 전제로 한 유효성 논의는 불필요하고 실익이 없다. 실제로 포괄임금제의 유효성에 대해서 변화된 판례법리를 제시한 2009년 판결의 원심¹⁵⁾에서는 조리사에 대한 포괄임금계약이 성립한다고 판단한 다음, 지급된 수당액이 근로기준법이 정한 기준에 미달하여 그 부분에 한해 무효라고 판단하였다. 이들 판례를 기점으로 해서 학설에서도 이를 구별하여 포괄임금제에

10) 대법원 2002.6.14. 선고 2002다16958 판결.

11) 대법원 2009.12.10. 선고 2008다57852 판결. 또한 같은 날에 동일한 회사에서 동일한 사실관계에 대해 동일한 취지로 대법원 2009.12.10. 선고 2008다45101 판결이 있다.

12) 대법원 2010.5.13. 선고 2008다6052 판결.

13) 김지형, 앞의 논문, 14-15쪽.

14) 김지형, 앞의 논문, 14쪽.

15) 서울중앙지법 2007.12.13. 선고 2007나2861 판결.

대한 견해가 다수 제기되어 왔다.¹⁶⁾

2. 포괄임금제의 성립여부

이전 판례법리를 보면, 대법원은 “근로시간, 근로형태와 업무의 성질 등을 참작하여 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서 근로자의 승낙”을 성립여부의 판단기준으로 하고 있다. 대법원은 2009년 판결에서 “포괄임금제에 관한 약정이 성립하였는지 여부는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야” 한다고 판시하였다.¹⁷⁾ 새롭게 제시된 이와 같은 법리는 성립여부에 대한 판단임을 분명히 하면서 판단의 고려요소가 많아지고 어느 측면을 특히 중시하기보다 종합적으로 판단한다는 점에서 기존의 법리와 다르다.

1) 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상되는 경우

대법원은 이전에는 판례법리상으로도 “근로형태와 업무의 성질 등을 참작하여 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는” 목적의 포괄임금제를 인정하였다.¹⁸⁾ 뿐만 아니라 대법원은 예를 들어 서울지하철공사의 청원경찰의 주업무가 “지하철 역사 등의 시설에 대한 경비 및 순찰이라는 근로형태의 특수성 때문에 근로기준법상의 기준 근로시간을 초과한 연장근로와 야간, 휴일근로가 당연히 예상”된다는 이유 등으로 포괄임금계약이 체결되었다고 판단하였다.¹⁹⁾ 또한 아파트경비원에 대한 사건에서

16) 정재현, 앞의 논문; 김진석, “포괄임금계약의 허용범위 - 대서판결: 대법원 2010.5.13. 선고 2008다6052 판결-”, 『노동법실무연구』 제1권, 노동법실무연구회, 2011; 강선희, “포괄임금제의 성립 및 유효성 판단기준, 『노동법포럼』 제10호, 노동법이론실무학회, 2013; 이광선, “포괄임금 약정의 효력과 문제점-대판 2010.5.13., 2008다6052를 중심으로”, 『저스티스』, 한국법학원, 2014.

17) 대법원 2009.12.10. 선고 2008다57852 판결

18) 대법원 1997.4.25. 선고 95다4056 판결.

도 대법원은 “경비·순찰이라는 근로형태의 특수성으로 인하여 근로기준법상의 기준 근로시간을 초과한 연장근로, 야간근로 및 휴일근로가 당연히 예상된다는” 이유 등으로 포괄임금계약이 체결되었다고 판단하였다.²⁰⁾

그러나 2010년 대법원은 포괄임금제가 성립하는지 여부에 대해 아래와 같이 설명하였다.

“비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 명백히 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우는 포괄임금제에 해당하지 아니한다고 할 것이고, 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의가 있거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선불리 단정할 수는 없다.”²¹⁾

대법원은 위와 같은 판례법리를 바탕으로 하여 매일 고정적으로 연장근로가 발생하는 버스회사에서 이를 명시적으로 정한, 연장근로에 대한 단체협약상의 합의가 포괄임금제에 대한 합의였다는 회사의 주장을 배척하였다. 더 나아가 대법원은 환경미화원에 관한 사건에서는 기본급과 각종 수당을 명백히 구분하고, 통상임금을 설정하고 이를 기준으로 시간외근무수당 등을 산정하고 있는 경우에 비록 규정에 ‘포괄임금형식으로 지급한다’는 표현이 사용되었음에도 불구하고 포괄임금제의 성립을 부정하였다.²²⁾

2) 명시적 근거가 없는 경우 묵시적 동의의 인정 문제

대법원은 2009년 이전 판결에서는 격일제 경비원에 대한 사건에서 단체협약이나 취업규칙, 근로계약 등에서 명시적인 근거가 없음에도 불구하고

19) 대법원 1997.4.25. 선고 95다4056 판결.

20) 대법원 2002.6.14. 선고 2002다16958 판결.

21) 대법원 2009.12.10. 선고 2008다57852 판결.

22) 대법원 2011.9.8. 선고 2011다19218 판결.

고 여러 수당을 이의 없이 임금을 받은 사실을 들어 포괄임금계약의 성립을 인정하였다.²³⁾

대법원은 2016년 건설일용직 근로자에 대한 사건에서 아래와 같이 판례법리를 제시하였다.

“단체협약이나 취업규칙 및 근로계약서에 포괄임금이라는 취지를 명시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 그 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 할 것이다.”²⁴⁾

대법원은 여전히 묵시적 합의의 성립을 부정하지는 않으나 이러한 합의를 인정하기 위해서는 ‘합의가 있었다고 객관적으로 인정되’어야 한다고 보았다. 위 사건은 건설 일용직의 일당으로 일당임금을 받은 것에 대한 것이고, 또한 사실관계가 분명하지 않아, 이전 판례법리와 달리 이의 없이 수령하였더라도 묵시적 합의가 제한되는 사례로 보기는 힘들다. 그렇지만 판례법리 자체에 ‘합의 인정의 객관성’을 제시하여 향후 제한될 수 있는 여지를 열어 둔 것으로 보인다.

학설에서는 포괄임금제의 성립에 대한 판단에서 묵시적 동의를 인정하는 견해가 있다.²⁵⁾ 그렇지만 다수의 견해는 묵시적 동의를 인정하지 않고 있다. 어떤 견해는 수년간 이의 없이 임금을 수령하였다는 것만으로 묵시적으로 승낙하였다고 보는 것이 매우 의제적이라고 비판한다.²⁶⁾ 다

23) 대법원 1984.1.24. 선고 83도2068 판결; 대법원 2005.8.19. 선고 2003다66253 판결.

24) 대법원 2016.10.13. 선고 2016도1060 판결

25) 신수길, “포괄임금제에 의한 임금지급계약이 유효하기 위한 요건”, 『대법원판례해설』 제32호, 1999, 193쪽.

른 견해는 근로기준법상 근로조건의 서면명시 의무가 있고, 근로시간 유연화와 관련하여 서면합의를 필요로 하고, 포괄임금제 자체는 제56조의 예외라는 점에서 비록 구두일지라도 명시적인 동의가 필요하다고 본다.²⁷⁾

3. 포괄임금제의 유효성

대법원은 이전의 판결에서 포괄임금제의 유효성에 대해서 “근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 그 계약은 유효하다고 할 것이고, 여기에서 근로자에게 불이익이 없어야 한다는 것은 단체협약이나 취업규칙에 구체적인 임금지급기준 등이 규정되어 있는 경우에 그러한 규정상의 기준에 비추어 보아 불이익하지 않아야” 한다고 설시하였다.²⁸⁾

그런데 대법원은 2010년 대법원판결을 통해 유효성 인정 법리를 아래와 같이 재정립하였다.

예외적으로 감시단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 (...) 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다 할 것이다.

이전의 법리와 비교해 보면, 유효성이 인정되는 경우가 근로시간 산정이 어려운 경우로 한정되어 있음을 알 수 있다.

대법원은 더 나아가 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아닐 경우의 판단법리를 아래와 같이 제시한다.

26) 송명호, 앞의 논문, 75면; 노동법실무연구회, 『근로기준법주해III』, 박영사, 2010, 157쪽.

27) 하갑래, 앞의 논문, 352-353쪽.

28) 대표적으로 대법원 1997.4.25. 선고 95다4056 판결.

위와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 달리 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 앞서 본 바와 같은 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 할 것이므로, 이러한 경우에도 근로시간 수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결하는 것은 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다.

한편 근로기준법 제15조에서는 근로기준법에 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 하면서(근로기준법의 강행성) 그 무효로 된 부분은 근로기준법이 정한 기준에 의하도록 정하고 있으므로(근로기준법의 보충성), 근로시간의 산정이 어려운 등의 사정이 없음에도 포괄임금제 방식으로 약정된 경우 그 포괄임금에 포함된 정액의 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 때에는 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의해 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다.”²⁹⁾

대법원은 바로 위의 인용된 판례법리에서 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아닌 경우의 포괄임금제는 허용될 수 없다고 밝힌다. 그런데 바로 그러한 경우에 모두 무효가 되는 것은 아니고, 근로기준법에 미달하는 부분에서만 무효가 되어 이에 대한 차액을 지급할 의무가 있다고 대법원은 말한다. 허용되지는 않는데 무효가 되지 않는 부분이 있다는 것은 모순적이다. 이러한 모순성을 피하려면 허용될 수 없는 것은 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니더라도 ‘근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는’ 것에 한정된다. 바로 이 경우가 뒷부분에서 말하는 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 경우에 해당한다.

이렇게 볼 때 대법원이 위 판례법리를 통해 포괄임금제의 유효성에 대

29) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.

해 밝히고자 하는 것은 2가지이다. 우선 근로시간의 산정이 어려운 경우에는 “달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때” 포괄임금제가 유효하다. 두 번째로 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’가 아니면 포괄임금제에 의해 지급된 수당이 근로기준법에서 정한 기준에 미달하지 않을 때 유효하다. 대법원은 최근의 사건에서 이와 같은 취지로 재정립해 제시하였다.³⁰⁾

예외적으로 이전 판례법리를 그대로 실시한 듯 보이는 판결이 있다. 대법원은 금아리무진 사건에서 “(...)이른바 포괄임금제에 의한 임금지급 계약 또는 단체협약이 체결되었다고 하더라도 그것이 근로기준법이 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 포함하는 등 근로자에게 불이익하지 않으면 유효하다”고 판례법리를 제시하였다.³¹⁾ 그러나 2010년 이전의 판례법리와 유사하지만, 인용문의 강조 밑줄 부분이 새로이 추가되었다. 이것이 추가됨으로써 이 판례법리에 의해서도 근로시간의 산정이 가능한 경우에는 포괄임금제하에서 지급된 수당이 법정수당에 미달할 경우에는

30) 대법원 2014.6.26. 선고 2011도12114 판결. “감시·단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 아니한 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다.

그러나 위와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 하므로, 이러한 경우에 앞서 본 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결한 때에는 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는지를 따져, 포괄임금에 포함된 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달한다면 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금 지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의하여 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다.”

31) 대법원 2012.3.29. 선고 2010다91046 판결.

여전히 무효가 될 수 있다.

대법원은 2009년 판결에서 위와 같은 판례법리를 실시하는 것에 더해서 이전의 포괄임금제와 관련한 판결들의 의미를 명확히 하였다. 즉 감시·단속적 업무를 수행하는 청원경찰³²⁾이나 아파트 경비원³³⁾에 대한 이전의 판결에서 대법원이 법정 수당과 포괄임금으로 지급된 제 수당과의 차액을 지급하는 것을 배척한 것은 모두 근로형태나 업무의 성질 등에 비추어 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’에 해당하기 때문이라고 보았다. 근로시간의 산정이 가능한 경우에도 포괄임금계약이 유효하게 성립할 수 있다는 취지는 아님을 명확히 하였다.

그러나 위 대법원 판례법리는 근로시간의 산정이 가능한 경우인데도 포괄임금제가 유효하다고 본 이전의 대법원 판례와 충돌될 수 있다. 예를 들어 공장 일용직 주부 사원에 대한 포괄임금제에 대해 대법원은 1996년 유효하다고 판단하였다.³⁴⁾ 이 사건의 내용을 보면 근로시간의 산정이 가능한 것은 명확하기 때문에, 실제로 근무한 시간에 따라 계산된 수당과 법정 수당의 차액이 발생한다면, 이 부분에 대해서는 포괄임금제가 무효가 되고 사용자는 그 차액을 지급할 의무가 있다고 볼 것이다. 또한 대법원이 과거 제분공장 직원에 대한 포괄임금제의 유효성을 인정한 것³⁵⁾도 현재의 법리로 보면 달리 적용될 수도 있을 것이다.

다음으로 제기되는 문제는 ‘근로시간 산정이 어려운 경우’의 유효성 판단에 대한 것이다. 대법원은 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’라고 인정된다면, ‘달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될’ 때 혹은 ‘단체협약 또는 취업규칙의 내용에 비추어 보아 근로자에게 불이익’하지 않아야 유효하다고 본다. 당연히도 근로시간의 산정이 어려운 경우라고 인정되기 때문에 법정 기준을 근거로 하여 차액지급과 같은 불이익의 주장은 인정되지 않는다.

불이익 여부의 판단기준이 되는 단체협약 또는 취업규칙은 근로시간의

32) 대법원 1997.4.25. 선고 95다4056 판결.

33) 대법원 2002.6.14. 선고 2002다16958 판결.

34) 대법원 1998.3.24. 선고 96다24699 판결.

35) 대법원 1992.2.28. 선고 91다30828 판결.

산정이 어려운 경우로 판단되는 근로자에게 적용되는 단체협약이나 취업규칙을 말한다. 대법원은 일용직 주부사원에게 적용되는 포괄임금제가 불이익한지 여부에 대해서는 이 사원에게 적용되는 취업규칙이나 단체협약이 없기 때문에 근로계약서의 내용에 비추어 보아야 하고, 이 일용직 사원과 일반사원과의 임금비교가 필요한 것은 아니라고 판단하였다.³⁶⁾ 이렇게 보면 대법원의 유효성 판단기준은 실질적인 판단에 있어 별다른 의미가 없을 것으로 보인다. 포괄임금제가 문제되는 근로자들에게 적용되는 근로계약, 취업규칙, 단체협약에는 명시되었다면 포괄임금제 성립의 근거가 되는 조항이 있을 뿐이어서, 불이익성을 판단할 만한 다른 기준도 발견하기 어려울 것이기 때문이다. 이와 반대로 만약 근로계약, 취업규칙, 단체협약에 명시되지 않았다면 이것들은 불이익성 판단에 준거가 되지 못할 것이다. 이제까지의 사례를 보면 근로시간의 산정이 어려운 경우이면서도 유효성이 부정된 사례는 없는 것으로 보인다. 이렇게 보면 근로시간의 산정이 어려운 경우로 되면 거의 모두 다 포괄임금제가 유효하게 될 수 있을 것이다.

학설에서는 이러한 점을 반영하여 단체협약이나 취업규칙 등이 아닌 다른 사정도 적극적으로 고려해야 한다고 보는 견해가 많다. 이 견해들은 예를 들어 동종 또는 유사한 업무의 근로자와의 비교를 통해서 사업장 내에서 동일노동 동일임금의 원칙을 고려할 수 있다고 보거나.³⁷⁾ 그렇지 않더라도 지역의 동종 업무의 근로자와 비교하는 등 여러 가지 사정을 고려할 수 있다고 본다.³⁸⁾

위와 달리 궁극적으로는 최저임금법상 최저임금의 기준에 미달하지 않는 것이 기준이 될 수 있다고 보는 견해가 있다.³⁹⁾ 그렇지만 근로시간의 산정이 어려운 경우이면 총근로시간의 산정 또한 어려워 최저임금에 미달하는지 여부를 판단하기 어려운 경우가 대부분일 것이다. 이 견해가 최저임금의 기준에 미달하지 않는지를 판단하는 것의 예로서 들고 있는

36) 대법원 1998.3.24. 선고 96다24699 판결.

37) 김지형, 앞의 논문, 165쪽; 송명호, 앞의 논문, 82쪽.

38) 강성태, “포괄임금제 성립여부의 판단기준 및 노사합의에 의한 통상임금 변경의 효력”, 『노동법학』 제33호, 2010, 274쪽; 정재현, 앞의 논문, 111쪽.

39) 강선희, 앞의 논문, 60쪽.

감시·단속적 근로는 후술하는 바와 같이 근로시간의 산정이 가능한 경우로 보아야 하는 것이어서 적절한 예가 되지 못할 것이다. 근로시간의 산정이 어려운 경우의 예로서는 후술하는 도급제 근로자가 있다. 최저임금법은 도급제 근로 형태에 대하여 통상의 최저임금액이 적용될 수 없는 경우로 보아 생산고나 업적의 일정단위에 의해 정하도록 하고 있으나(최저임금법 제5조 제3항, 시행령 제4조), 현재까지 이에 대해 구체적으로 정해진 바가 없다.⁴⁰⁾

4. ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’의 해석

1) ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’의 의의

앞서 언급한 바와 같이 2010년 판결에 의해 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’를 기준으로 유효성 판단 기준이 달라진다. 2010년 판결에서 근로시간의 산정이 어려운 경우라고 명시적으로 인정한 감시·단속적 근로를 제외하고는 어떠한 경우가 그러한 경우에 해당하는지에 대해 구체적인 기준을 제시한 바가 없다.⁴¹⁾ 그렇기 때문에 앞서 언급한 바와 같이 2010년 판결 이전의 대법원 판결 중 감시·단속적 근로가 아닌 업종과 근무형태에서 포괄임금제의 유효성을 인정한 사례들이 있는데, 2010년 대법원판결의 판례법리에 따라 향후 어떠한 판단이 내려질지 쉽게 단정

40) 대법원은 홍익회 도급제 성과급 사원에 대한 사건에서 이러한 경우에는 법원이 최저임금법에 따라 “근로자의 생계비, 유사근로자의 임금, 노동생산성 등을 고려함과 아울러 원고들이 체결한 근로계약의 내용, 근로의 형태와 방식, 근로시간, 근로의 밀도, 임금의 산정방식, 원고들과 같은 성과급영업인 혹은 성과급영업보조원들의 임금 산정 기준 시간 동안의 평균적인 생산고(판매량) 및 그에 따른 성과급 수준, 소득분배율, 노동부장관이 일반적으로 고시한 최저임금액, 현행 최저임금법이 예정하고 있는 감시·단속적 근로에 대한 최저임금액의 감액비율 기타 기록에 나타난 제반 사정을 참작하고, 원고들의 임금 지급방식이 시간외 근로수당 등 법정 제 수당이 포함된 월급 단위의 포괄임금제라는 점을 감안하여 원고들에게 적용될 적절한 월 최저임금액을 정할 수 밖에 없다”고 판시하였다(대법원 2007.6.29. 선고 2004다48836 판결)

41) 전운구, “가산수당을 합산한 포괄임금제의 효력요건”, 『조정과 심판』 제43호, 중앙노동위원회, 2011, 37쪽.

하기 어렵다.

그렇다면 앞으로 이러한 대법원의 법리에 따라 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’가 어떠한 것인지가 중요한 문제가 된다. 이에 대해서는 근로시간의 계산이 ‘불가능’한 경우가 아니면 실제로 ‘가능한’ 경우에도 근로시간의 계산이 ‘어려운’ 경우라고 하여 일정한 범위에서 근로기준법상 근로시간 규제를 사실상 포기하는 태도라는 비판이 있다.⁴²⁾ 이러한 비판이 가능한 것은 판례법리가 근로시간의 계산이 가능하나 이를 위해서 행정적으로 별도의 인력과 비용을 필요로 할 때 이러한 점은 근로시간의 어려운 경우의 판단에서 어느 정도로 인정되어야 할지에 대해 설명하고 있지 않기 때문이다.

현재의 판례법리를 비판하면서 ‘근로시간 산정이 어려운 경우’를 ‘실근로시간의 산정이 불가능하거나 산정하는 것이 무의미한 경우’로 엄격하게 해석하여야 한다는 견해가 제기된다.⁴³⁾ 이와 달리 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’를 위와 같이 엄격하게 해석하는 것에 반대하는 견해가 있다.⁴⁴⁾ 이 견해는 그 근거로 우선 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’는 제 58조의 요건에 해당하는 것이어서 이 개념은 실근로시간의 산정이 객관적으로 어려운 경우는 법률적으로 상정되어 있다는 점을 든다. 다음으로 논리적으로도 제58조와 제63조의 요건이 갖추어지지 않았더라도 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’가 있을 수 있다는 점을 든다.

사건으로는 근로시간의 산정이 어려운 경우를 ‘실근로시간의 산정이 불가능하거나 산정하는 것이 무의미한 경우’로 파악하는 견해에 찬성한다. 그 근거로는 근로기준법상 근로시간 유연화제도나 적용제외조항과의 관계가 강조되어야 한다고 본다. 근로기준법은 근로시간이 어려운 경우를 상정하여 사업장 밖 간주근로시간제와 재량근로제(제58조)를 도입하였고, 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용하기 곤란하거나 적용할 필요가 없는 경우에 대비하여 근로시간 적용제외 규정(제63조)을 두고 있다. 이 제

42) 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 『성공판법학』 제23권 제3호, 2012, 853쪽 참조.

43) 이광선, 앞의 논문, 354쪽.

44) 박순영, “근로기준법상 근로시간의 규제와 포괄임금제”, 『대법원판례해설』 제 83호, 법원도서관, 2010, 819-820쪽.

도와 규정은 관련 업무에 대해 일정한 요건 하에 예외적으로 허용하는 것이다. 그런데 이러한 요건이 갖추어지지 않았음에도 불구하고 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’로 파악한다면, 위 제도와 규정은 의미가 없어지게 될 것이다.

또한 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’가 법률적으로 상정가능한 것이라는 점은 타당하지만 이 점은 세부적으로 구별해서 판단할 필요가 있다. 제58조의 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’는 ‘사업장 밖 간주근로시간제’의 요건으로서 존재하는 것이고, ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’를 폭넓게 보는 위의 견해에 따르면 이 경우에는 사업장 밖 근로뿐만 아니라, 재량근로제에 해당하는 업무도 포함되고, 근로시간의 적용제외 업무도 포함하는 것이어서 훨씬 더 포괄적이다. 각각의 경우를 구별하여 근로기준법에서 예외적으로 일반적인 근로시간 규제를 벗어나는 것을 허용하고 있는데, 위 견해에 따르면 판례법리는 예외적으로 일정한 요건을 갖춘 경우에만 허용되는 것에 추가하여 중복적으로 동일한 근로형태에 대해 별도로 일반적인 근로시간 규제의 예외를 허용하게 되는 셈이다. 그래서 제58조나 제63조가 적용이 될 수 있는 경우를 근로시간의 산정이 어려운 경우에서 제외한다면, 논리적으로 근로시간의 산정의 어려운 경우가 상정가능하다고 할지라도 그러한 경우는 대폭적으로 줄어들어 산정이 불가능하거나 산정이 무의미한 경우로 협소해질 것이다.

2) 근로형태별 ‘근로시간 산정이 어려운 경우’의 판단

(1) 감시·단속적 근로

감시·단속적 근로자로서 사용자가 고용노동부장관의 승인을 얻은 경우 근로기준법의 근로시간, 휴게, 휴일 규정을 적용하지 아니한다(제63조 제3항). 적용을 제외하는 이유는 감시·단속적 근로는 근로제공에 대해 정신적·육체적 피로가 적거나 근로가 간헐적으로 이루어져 휴게시간 또는 대기시간이 많기 때문으로 본다.⁴⁵⁾ 고용노동부장관의 승인을 받지 않으면 감시·단속적 근로라고 하더라도 근로시간, 휴게, 휴일, 규정이 적

45) 임종률, 『노동법』, 박영사, 2017, 468쪽.

용된다. 그리고 근로시간, 휴게, 휴일 규정만 적용이 제외되어 야간근로, 연차휴가 등은 적용이 배제되지 않는다고 해석된다.

2010년 판결은 감시·단속적 근로를 근로시간 산정이 어려운 경우의 대표적인 것으로 예시하고 있다. 2010년 이전에는 감시·단속적 근로에 대해 대부분의 대법원판결이 양자를 명확히 구별한 것은 아니지만, 포괄 임금제의 성립과 유효성을 인정하였다. 그러한 감시·단속적 근로는 아파트 경비원⁴⁶⁾, 청원경찰⁴⁷⁾, 보일러 운전기사⁴⁸⁾ 등이다. 감시·단속적 근로의 성립 및 유효성 인정은 해당 근로가 근로시간에 대한 적용제외규정(제63조)에 의해 고용노동부 장관의 승인을 받았는지 여부에 관계없이 이루어졌다. 예를 들어 청원경찰의 사례에서 적용제외 승인을 받지 않은 경우에도 포괄임금제의 성립 및 유효성이 인정되었다.⁴⁹⁾ 예외적으로 포괄임금제의 성립을 인정하지 않은 대법원 판결이 있다.⁵⁰⁾ 이 판결은 대학교 수위에 대한 것으로 이 업무가 근로시간 산정이 어려운 경우가 아니라는 것이 아니고, 단체협약과 취업규칙의 해석상 중간에 원래 주야간 근무이었으나 격일제 근무로 불리하게 변경되었고, 이에 대해 동의하였다고 할 수도 없는 점 등을 이유로 포괄임금제가 성립하지 않는다고 판단한 것이다.

감시·단속적 근로가 근로시간의 산정이 어려운 것인가에 대해서는 견해의 대립이 있다. 먼저 근로시간의 산정이 어려운 업무에 해당한다고 보는 견해⁵¹⁾는 감시·단속적 근로에 흔히 수반되는 격일제 교대근무와 같은 근무형태가 근로시간의 계산을 어렵게 한다고 주장하지는 않는다. 격일제 근무라고 하여도 근로시간과 휴게시간을 명확히 구별하여 관리된다면 근로시간의 산정이 가능하다고 볼 수도 있다. 오히려 이 견해는 연

46) 대법원 1983.10.25. 선고 83도1050 판결; 대법원 1984.1.24. 선고 83도2068 판결; 대법원 1993.5.27. 선고 92다33398 판결; 대법원 2002.6.14. 선고 2002다16958 판결; 대법원 2005.8.19. 선고 2003다66253 판결.

47) 대법원 1997.4.25. 선고 95다4056 판결

48) 대법원 2002.8.27. 선고 2000다65383,65390 판결

49) 다른 사례로는 격일제 경비원에 대한 것으로 대법원 2005.8.19. 선고 2003다66253 판결이 있다.

50) 대법원 1997.7.22. 선고 96다38995판결

51) 송명호, 앞의 논문; 박순영, 앞의 논문.

장, 야간, 휴일근로에 대하여 가산임금을 지급하는 조항(제56조)의 적용에는 전제조건이 있다고 본다. 그것은 해당업무가 일정수준의 근로밀도가 수반되어 기준근로시간의 근로만으로 노동력 소모가 한계에 도달해야 한다는 것이다.⁵²⁾ 그런데 감시·단속적 근로는 이러한 수준의 근로밀도에 미달하기 때문에 제56조가 적용되지 않는다고 이 견해는 보는 것이다.

일반적으로 감시·단속적 근로가 근로시간의 산정이 어려운 업무에 해당하지 않는다고 보는 견해⁵³⁾는 특정한 근로형태를 근로밀도가 낮은 것으로 제56조의 적용대상으로 보지 않는다고 볼 수 있는 법적 근거가 전혀 없다는 점을 강조한다. 휴게시간과 구별하여 대기시간은 사용자의 지휘·명령하에 있는 것으로 근로기준법상의 근로시간에 해당하기 때문이다. 이 점은 2012년 근로기준법 개정으로 제50조 제3항에 명시되어 있기까지 하다. 다음으로 이 견해는 감시·단속적 근로의 근로밀도가 낮은 것은 이미 기준임금의 책정에서 반영하면 족한 것이라고 본다.⁵⁴⁾ 최저임금법상 감시·단속적 근로로서 고용노동부 장관의 승인을 받으면 최저임금을 10% 감액하는 것(최저임금법 제5조 제2항 2호, 시행령 제3조)은 기준임금이 통상의 최저임금보다 더 낮게 책정하는 것을 가능하게 한다는 점에서 이 견해를 뒷받침하는 근거가 될 수 있을 것이다.

감시·단속적 근로가 일반적으로는 근로시간의 산정이 어려운 업무가 아니라고 하여도 근로기준법 제63조와 관련해서 달리 볼 측면이 있다. 제63조의 적용제외 승인을 받은 경우 근로시간, 휴일, 휴게 규정이 적용되지 않기 때문에 사용자는 감시·단속적 근로에 대하여 연장근로수당, 휴일근로수당을 지급할 의무가 없다. 따라서 유효한 포괄임금제와 제63조의 적용제외는 정확히 같지는 않지만 사용자에게 유사한 효과를 부여할 수 있다.

제63조의 적용제외 승인의 유무와 관련하여 감시·단속적 근로에 대한 견해는 다시 나눌 수 있다. 우선 감시·단속적 근로를 제63조의 적용제

52) 송명호, 앞의 논문, 68쪽.

53) 이병한, “포괄임금제의 성립 여부를 판단하는 기준”, 『대법원판례해설』 제81호, 법원도서관, 2010; 김홍영, 앞의 논문; 정재현, 앞의 논문.

54) 정재현, 앞의 논문, 105-107쪽.

외 승인여부와 관계 없이 근로시간의 산정이 어려운 경우라 파악하는 견해가 있다. 이 견해는 감시·단속적 근로가 제56조 가산임금의 전제가 되는 정도의 근로밀도가 없다는 것을 이유로 하기 때문에 고용노동부장관의 승인을 받았는지는 근로시간이 어려운 경우에 해당하는지에 대한 판단에 영향을 주지 못한다. 즉 승인을 받지 않았더라도 근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당하여 포괄임금제가 유효할 수 있는 것이다.⁵⁵⁾ 이러한 견해에 반대하여 근로기준법 제63조의 적용제외의 승인을 받은 경우에만 근로시간의 산정이 어려운 경우로 파악하여 포괄임금제가 적용된다고 보는 견해가 있다.⁵⁶⁾ 이 견해는 근로기준법 제63조의 적용제외 승인 여부에 관계 없이 근로시간의 산정이 어려운 경우라고 본다면, 이 조항이 사문화하는 결과가 된다고 하여 첫 번째의 견해를 비판한다.⁵⁷⁾

필자는 감시·단속적 근로에 대한 포괄임금제 허용으로 근로기준법 제63조 적용제외규정이 사문화된다는 의견에 동의한다. 근로시간의 산정이 어려운 경우로 포괄임금제가 허용되면 법정 수당을 별도로 지급할 필요가 없기 때문에 사용자가 굳이 제63조의 적용제외 신청을 하지 않을 것이기 때문이다. 더구나 감시·단속적 근로가 적용제외 승인을 받기 위해서는 일정한 요건이 필요하다. 근로감독관 집무규정을 보면 실제로 감시·단속적 근로에 대한 고용노동부장관의 적용제외 승인은 일정한 요건을 갖춘 경우에만 인정된다. 예를 들어 감시 근로라 하더라도 고도의 정신적 긴장이 요구되는 경우나, 1일 근로시간이 12시간 이내인 경우나, 단속 근로라 하여도 대기시간에 근로자가 자유로이 이용할 수 있는 수면 또는 휴게시설이 확보되어 있지 않는 경우 등은 적용제외의 승인이 되지 않는다.⁵⁸⁾ 더구나 포괄임금제를 실시하면 제63조의 승인을 받았다고 하더라도 적용된다고 해석하는 야간근로 가산임금 등을 지급할 필요가 없기 때문에 사용자에게는 이점이 더욱 커진다.

더 나아가 적용제외신청의 승인여부와 무관하게 근로시간의 산정이 어

55) 박순영, 앞의 논문, 817쪽.

56) 하갑래, 앞의 논문, 346쪽; 김홍영, 앞의 논문, 854쪽.

57) 이광선, 앞의 논문, 345면.

58) 근로감독관집무규정(2016.3.9. 훈령 제185호), 제68조.

려운 경우로 보아 포괄임금제를 허용하지 않아야 한다는 견해가 가능하다.⁵⁹⁾ 이 견해는 제56조의 가산임금 적용과 제63조의 적용제외 양자를 연계하지 않고 독자적으로 보는 것이다. 이렇게 보면 감시·단속적 근로에 대해 제63조의 적용제외승인을 받았다고 하더라도 제56조와 관련하여서는 여전히 근로시간의 산정이 가능한 경우로 포괄임금제가 허용되지 않게 된다. 따라서 적용제외 승인을 받은 경우라 하더라도 적용제외의 대상이 되지 않는다고 해석되는 야간근로의 가산임금을 포함하여 지급한 포괄임금제 약정은 포괄임금제 약정은 유효하지 않게 된다. 야간근로에 대한 규제를 근로시간, 휴게, 휴일과는 다른 취지로 보아 이를 제63조의 적용제외의 대상규정에서 제외한 것인데도 야간근로에 대한 가산임금까지를 포함하는 포괄임금제가 허용이 되면 사실상 제63조의 적용대상규정이 확대된 것에 다름 아니게 된다. 비록 현재 허용되는 포괄임금제에 포함되는지 여부가 쟁점이 되고 있지만 미사용 연차휴가 근로수당에 대해서도 야간근로 가산수당과 유사하게 말할 수 있을 것이다.

(2) 사업장 밖 근로와 재량근로

가) 사업장 밖 근로

사업장 밖 근로에 대해서는 대법원은 일찍부터 포괄임금제를 인정하는 경향을 보였다. 예를 들어 대법원은 1983년 부산과 서울사이를 왕복 운행하고 그 외 각 지방 등을 장거리 운행하는 트레일러 운전수에 대하여 근로시간 수가 일정하지 아니하고 또한 실제 근로시간을 파악할 수 없다는 이유 등으로 포괄임금계약의 유효성을 인정하였다,⁶⁰⁾ 대법원은 또한 1990년 충남일원과 경기, 서울 등지를 운행하여야 하는 시외버스 운전기사에 대하여 운행코스, 교통상황 및 운전자들의 근무태도 등에 따라 운행시간이 일정하지 아니하여 근로시간을 정확하게 파악하기 어렵다는 이

⁵⁹⁾ 명시적이지는 않지만, 감시·단속적 근로가 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라는 주장을 전제로 하여 근로기준법 제63조가 적용되는 업무에 대하여 제63조의 적용제외가 적용되는 조항들을 제외하고 근로기준법 등이 정한 법정기준에 미달하는지 여부를 판단하여 포괄임금제의 유효성을 판단하여야 한다는 견해(정재현, 앞의 논문, 110-111쪽)가 이와 유사할 것이다.

⁶⁰⁾ 대법원 1983.9.13. 선고 82다카49 판결.

유 등으로 포괄임금제의 유효성을 인정하였다.⁶¹⁾

한편 근로기준법에서는 사업장 밖 근로에 대한 간주근로시간제가 1997년 도입되었다. 그 결과로 근로기준법은 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우 소정근로시간을 근로한 것으로 본다(제58조 제1항). 그렇지만 이러한 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다(제58조 제1항 단서). 그러나 근로자가 사업장 밖에서 근무한다고 하더라도 근무시간과 방법을 안정적으로 측정할 수 있는 경우에는 사업장 밖 간주근로시간제가 적용되지 않는다.⁶²⁾

이와 같은 상황에서 포괄임금제와 관련하여 사업장 밖 근로는 근로시간의 산정이 어려운 경우라고 보는 견해가 다수이다.⁶³⁾ 이러한 견해 중 하나는 근로의 장소 자체가 사업장 밖이어서 근로시간의 산정이 어려워 근로자대표와의 서면합의(제58조 제2항)가 없으면 해당 업무의 수행에 통상 필요한 시간이 어느 정도인지 확정하기 어렵기 때문에 포괄임금제의 대상이 된다고 본다.⁶⁴⁾ 위의 견해들과는 정반대로 사업장 밖 근로에 대해 포괄임금제가 유효하다고 보는 경우 사업장 밖 간주근로시간제의 활용을 저해할 것이라는 견해가 제기된다.⁶⁵⁾ 만약 사업장 밖 근로에 대해 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등을 통해 포괄임금제를 할 수 있다면, 사용자가 근로자대표와의 서면합의를 별도로 하여야 하는 간주근로시간제를 사용자가 활용할 이유가 없어지게 되기 때문이다. 그래서 사업장 밖 간주근로시간제를 적용할 수 있음에도 불구하고 포괄임금제를 도입하면 이러한 제도를 무력화시킬 수 있다. 따라서 이 견해는 근로기준법상 사업장 밖 근로의 규정의 요건을 충족하는 경우에만 근로시간의 산정이

61) 대법원 1990.11.27. 선고 90다카6934 판결.

62) 임종률, 앞의 책, 443면.

63) 송명호, 앞의 논문, 64-65쪽; 박순영, 앞의 논문, 820면; 이광선, 앞의 논문, 348면.

64) 송명호, 앞의 논문, 65면.

65) 하갑래·최미나, 『포괄임금제의 운영실태 및 개선방안에 관한 연구』 고용노동부 학술연구용역보고서, 2012, 81쪽. 이 단락 이하 동일.

어려운 경우로 파악되어야 한다고 본다.

그러나 포괄임금제에 대한 합의의 내용에는 ‘당해 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 필요한 시간’(제58조 제1항 및 제2항)을 정하는 것이 포함되므로 사업장 밖 근로에 대한 포괄임금제 합의 자체가 사업장 밖 간주근로시간제의 요건을 충족한 것으로 볼 수 있다.⁶⁶⁾ 사업장 밖 근로 등에 대해서는 포괄임금계약이 성립되었다고 강하게 추정할 수 있다고 보는 견해⁶⁷⁾도 이러한 의미에서 이해할 수 있을 것이다. 또한 사업장 밖 간주근로시간제에서 근로자대표와의 서면합의는 필수적 요건이 아니기 때문에 사업장 밖 간주근로시간제는 다른 근로시간제 유연화 제도와 달리 별도의 형식적 요건을 필요로 하지 않다. 이런 점을 감안하면 원칙적으로 사업장 밖 근로에 대해 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라고 볼 수 없을 것이다.

나) 재량근로

현행 근로기준법상 재량근로제(제58조 제3항)는 위 사업장 밖 간주시간제와 마찬가지로 1997년 근로기준법에 도입된 것이다. 재량근로업무는 전문적 업무로서 근로의 양보다 질이나 성과가 중시되어 근로시간을 일일이 계산하는 것이 적절하지 않은 것으로 인정되는 업무⁶⁸⁾로 시행령에서는 연구개발, 정보처리시스템의 설계·분석, 취재·편성·편집 업무, 디자인·고안 업무, 방송·영화의 제작 프로듀서·감독 업무 등을 그 업무로 정하고 있다(제31조). 이 재량업무의 업무시간 배분 등에 대해 사용자가 구체적인 지시를 하지 아니하고, 근로시간의 산정은 근로자대표와의 서면합의로 정한 것에 따른다(제58조 제3항 제2호, 제3호).

아직까지 재량근로업무에 대해 법원이 판단한 사례는 없는 것으로 보이지만, 사업장 밖 근로에 대한 법원의 판단을 보면, 재량근로업무에 대해서도 근로시간의 산정이 어려운 경우로 판단할 것 같다. 재량근로업무를 근로시간 산정이 어려운 경우로 볼 것인가에 대해서 견해 차이도 사

66) 하갑래, 앞의 논문, 347면.

67) 강성태, 앞의 논문, 272면.

68) 임종률, 앞의 책, 444쪽.

업장 밖 근로의 경우와 유사하다. 한편의 견해는 해당 업무가 시행령에서 정한 재량근로업무가 아니거나 근로자대표와의 서면합의가 없어 근로기준법 제58조의 재량근로 요건을 갖추었는지에 관계없이 근로시간의 산정이 어려운 업무로 본다.⁶⁹⁾ 다른 견해는 제58조 제3항의 요건을 갖추는 경우에 근로시간의 산정이 어려운 것으로 본다.⁷⁰⁾ 이 견해는 만약 재량근로업무를 근로시간이 산정이 어려운 경우로 보아 재량근로제의 요건을 갖추었는지와 관계없이 포괄임금제를 허용한다면, 사용자가 근로자대표와의 서면합의라는 별도의 요건을 갖추어야 하는 재량근로제를 굳이 도입할 필요성이 없을 것이라고 비판할 것이다.

사건으로는 감시·단속적 근로의 경우와 마찬가지로 재량근로제의 경우에도 가산임금 등의 지급을 위한 포괄임금제와 재량근로제 도입을 별개로 보아야 한다. 재량근로제에서 근로자대표와의 서면합의에 의해서 산정된 근로시간은 그 합의된 시간의 한도에서 연장근로, 야간근로, 휴일근로시간이 포함될 수 있다. 이와 같이 포함될 경우 그 합의된 시간에 근거해 연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당이 지급되고, 실제로 근로한 시간이 이보다 많다고 할지라도 사용자가 실제로 근로한 시간대로 앞의 수당을 계산하여 지급할 의무가 없다. 이러한 점에서 재량근로제는 포괄임금제와 유사한 효과를 가질 수 있다. 그렇기 때문에 현재의 재량업무제의 요건을 갖춘 경우에 별도로 포괄임금제를 허용하여야 할 이유가 없다. 재량근로에 대하여 근로시간의 산정이 어려운 경우에는 요건을 갖추어 재량근로제를 도입하면 되는 것이다.

(3) 일반 사무직 근로

재량업무와 같은 전문직 업무가 아닌 일반 사무직에 대한 포괄임금제가 문제된 판결은 거의 없어 보인다. 다만 매일 매일의 기상조건이 다른 해외건설현장의 관리직 직원에 대해서 포괄임금제가 성립할 여지가 있다고 보는 대법원 판결이 있다.⁷¹⁾ 또한 의료보험직원에 대하여 포괄임금제

69) 송명호, 앞의 논문, 65쪽; 박순영, 앞의 논문, 820쪽.

70) 하갑래, 앞의 논문, 347-348쪽.

71) 대법원 1991.4.23. 선고 89다카32118 판결.

가 문제가 되었으나 취업규칙상에 별도로 지급하는 시간외근무수당, 휴일 근무수당 등을 나열하고 있어 포괄임금제 약정 자체가 성립하지 않는다고 대법원은 보았다.⁷²⁾ 이러한 사례들은 해외에서의 관리업무와 기상조건의 변화라는 특수한 상황에 대한 것이거나, 연장근로 등이 통상적으로 발생하는 경우는 아닌 것으로 보여서 일반 사무직의 전형적인 상황에 대한 법원의 판단이라고 보기는 힘들다.

일반 사무직의 업무는 근로시간의 산정이 어려운 것은 출퇴근시간에 대한 기록을 하지 않고 연장근로 등의 사실에 대한 행정적인 근거가 없기 때문이다. 따라서 이 업무는 그 특성상 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라 ‘시간관리에 관한 운영행태의 관행’상 근로시간의 산출이 어려운 경우에 해당한다.⁷³⁾ 그렇기 때문에 일반 사무직의 업무는 근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당하지 않는다는 것이 다수의 견해로 보인다.⁷⁴⁾ 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라고 하여도 근로시간에 대한 기록이나 근거가 없는 경우 근로자가 현실적으로 입증하기가 쉽지 않을 것이다.⁷⁵⁾

(4) 도급 근로

임금이 실적·성과·능률에 의해 결정되는 도급 근로자에 대하여 근로기준법은 사용자가 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하도록 하고 있다. 이 조항의 취지는 근로자에게 책임 없는 사유로 대기시간이 길어져 근로자의 임금액이 감소하는 것을 방지하고자 하는 것이다.⁷⁶⁾ 그리고 최저임금법은 임금이 도급제 등으로 정하여져 있는 경우 시행령에 의해 통상의 최저임금액과 다르게 정할 수 있게 하고(제5조 제3항), 시행령은 이에 따라 근로자의 생산고 또는 업적의 일정단위에 의하여 최저임금액

72) 대법원 1995.7.28. 선고 94다54542 판결.

73) 송명호, 앞의 논문, 71면.

74) 송명호, 앞의 논문; 김홍영, 앞의 논문; 정동관 외5인, 『사무직 근로시간 실태와 포괄임금제 개선방안』, 한국노동연구원, 2016, 220면.

75) 김홍영, 앞의 논문, 853면.

76) 김형배, 『노동법』, 박영사, 2015, 362쪽; 하갑래, 『근로기준법』, 중앙경제사, 2015, 454쪽; 임종률, 앞의 책, 413쪽.

을 정하도록 규정하고 있다(제4조).

대법원은 위와 같은 도급 근로의 성격이 있는 경우에 포괄임금제의 성립과 유효성을 인정한 바 있다. 이것이 문제가 된 일련의 사건들⁷⁷⁾은 모두 철도구내와 열차 내에서 식품 및 물품 판매를 하고 있는 근로자에 대해서이다. 이 사건에서 대법원은 이 근로자가 기본급이 없이 상품판매액수의 일정비율로 산출된 성과급을 지급받고 있는 점을 근거로 ‘도급적 성격이 강한’ ‘근무형태의 특수성 및 업무의 성질’ 등을 종합적으로 고려하여 포괄임금제가 성립하고 또한 유효하다고 판단하였다.⁷⁸⁾

도급 근로자의 경우 임금이 근로시간이 아니라 전적으로 실적·성과·능률에 따라 결정되기 때문에 기준임금은 생산고 또는 업적의 일정단위당으로 책정될 수밖에 없다. 가산임금 등을 지급하기 위해 필요한 근로시간과 그에 따른 임금을 산출하기 어렵다. 도급 근로자가 사업장 내에서 근로하고, 일정한 출퇴근 시간이 있는 경우 근로시간을 알 수 있게 되나, 근로자가 받은 임금은 실적이나 성과에 따라 매달 달라져 가산임금의 계산에 어려움이 있다. 그리고 위에서 본 바와 같이 근로기준법 등에서 이러한 임금산정방식을 허용해주고 있는 것도 분명하다. 이런 점에서 도급 근로자의 경우에는 근로시간의 산정이 어려운 경우로 볼 수 있을 것이다.⁷⁹⁾

III. 규제론

1. 필요성

77) 대법원 1999.6.11. 선고 98다26385; 대법원 2003.3.28. 선고 2001두4801 판결; 대법원 2007.6.29. 선고 2004다48836 판결.

78) 대법원은 근무형태가 도급적 성격이 강한 점 이외에 업무의 내용이 단속적·간헐적이어서 휴게시간 내지 대기시간이 많은 점도 함께 고려하였다고 밝혔다.

79) 근로시간의 산정이 어려운 경우를 가장 협소하게 보아 그러한 경우가 극히 드물 것이라고 보는 견해에서도 도급제형 업무는 그 드문 사례의 하나로 꼽는다(정재현, 앞의 논문, 107면, 각주 79).

1) 장시간 근로의 억제

포괄임금제를 입법적으로 규제하여야 한다고 보는 견해가 가장 많이 내세우는 포괄임금제의 문제점은 장시간 노동을 고착시키는 기능을 한다는 점이다.⁸⁰⁾ 포괄임금제는 연장근로, 야간근로, 휴일근로를 상시적으로 수행한다는 전제로 하고 있다. 따라서 포괄임금제를 유효하다고 보는 것은 이러한 상시적인 장시간 근로를 합법화하여 유지하는데 도움을 준다는 것이다.

한 연구결과에 따르면 근로시간과 관련하여 위와 같이 기능하는 포괄임금제는 특히 화이트칼라(대졸 사무직, 영업직, 판매직, 서비스직, 전문직)에서 관행화되어 화이트칼라의 장시간노동을 은폐하고 유지하며 재생산한다.⁸¹⁾ 구체적으로 보면 포괄임금제 때문에 화이트칼라들은 장시간근로를 상시적으로 하면서도 제대로 보상받지 못한다. 또한 포괄임금제에 의해 약정된 시간외 근로보다 훨씬 더 많이 일하면서도, 기업은 포괄임금제로 인하여 근로시간의 기록이나 관리를 하지 않기 때문에 화이트칼라의 장시간 노동은 은폐되고 있다고 한다.

그렇지만 장시간 근로의 억제를 위해 포괄임금제에 대한 규제가 필요하다는 견해는 좀 더 면밀하게 볼 필요가 있다. 비록 사무직과 관련해서는 대법원이 판단한 바가 거의 없지만, 학설에서는 앞에서 서술한 바와 같이 대부분의 사무직에 대해서는 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라고 본다. 따라서 현행 사무직 근로에서 일정한 시간만을 연장근로 등으로 인정해주는 관행은 법적으로 엄밀하게 본다면, 연장근로 등의 한도만을 정한 것이어서 포괄임금제 약정이 아니라고 보거나, 포괄임금제 약정이라고 하더라도 유효하지 않기 때문에 실제의 근로시간에 따라 그 차액을 사용자가 지급해야 할 의무가 있는 것들이 대부분이다. 이러한 차원의 문제라고 하면 포괄임금제를 금지하거나 제한하는 입법까지를 포함한 포괄임금제에 대한 규제까지는 필요가 없을 것이다. 현재의 판례법에 따라 실제의 근로시간에 따라 정산을 받을 수 있도록 회사가 출·

80) 김홍영, 앞의 논문, 851쪽.

81) 배규식, “한국 장시간 노동체제의 지속요인”, 『경제와 사회』 95호, 2012, 155-157쪽.

퇴근 등의 근로시간을 엄격히 기록하여 관리하도록 하며, 더해서 현행의 판례법리에 따라 해석되는 기준으로 범위만 사례가 발생하지 않도록 근로 감독을 강화하는 것이 필요할 것이다.⁸²⁾ 사무직 근로와 관련해서만 보면 포괄임금제 입법은 출퇴근 기록의 관리 의무나 이에 대한 입증책임의 강화 등에 한정될 수 있다.

2) 근로기준법의 규율체제 이탈 방지

포괄임금제 약정이 유효하다고 인정되면, 제56조 가산임금 조항의 적용의 예외로서 인정되는 것이다. 그렇기 때문에 가산임금을 통해 초과근로를 제한하고 근로자에게 보상하는 제56조의 목적과 취지에 부합하지 않는다. 예를 들어 야간근로에 대하여 연소자와 임신 중인 여성에 대해 보호(제70조)를 무력화시킬 소지가 있는 점이 지적되고 있다.⁸³⁾ 포괄임금제는 당사자간의 합의가 항상적으로 존재한다고 봄으로써 개별적으로 연장근로가 필요할 때마다 당사자간의 합의를 요구한다고 하는 연장근로의 요건을 지키지 못하게 한다. 휴일근로의 경우도 마찬가지이다. 또한 포괄임금제에 연차휴가근로수당도 포함될 수 있다고 할 경우 근로자의 연차휴가권도 침해될 수 있다. 결국 포괄임금제는 여러 가지 근로기준법상의 제도에 부합하지 않는 측면이 많다.

또한 포괄임금제는 근로기준법상 근로시간 유연화제도의 적용에도 크게 영향을 준다. 앞서 보았듯이 예를 들어 재량근로제의 요건을 모두 갖추지 않아도 포괄임금제가 유효하다고 보는 경우 사용자는 굳이 근로자 대표와의 서면합의를 필요로 하는 재량근로제를 도입할 필요가 없다. 감시·단속적 근로에 대해서 적용제외 승인을 받지 않아도 포괄임금제가 유효하다면 사용자는 일정한 요건을 갖추어야 되는 적용제외 승인신청을 할 이유가 없다. 사용자는 적용제외 승인 신청을 하지 않더라도 포괄임금제를 통해서 적용제외 승인을 통해서 얻고자 하는 목적을 사실상 달성할 수 있다. 더 나아가 ‘포괄’임금제이기 때문에 예를 들어 적용제외조항

82) 도재형, 앞의 칼럼 참조.

83) 하갑래·최미나(2012), 앞의 보고서, 112쪽.

에서 제외된다고 하는 야간근로까지 포함하여 사용자는 해결할 수 있게 된다. 이러한 점들 때문에 포괄임금제는 근로시간 유연화제도의 적용에 방해요소로 작용된다. 이러한 점 때문에 법원이 특히 적용대상업무와 도입절차의 요건을 엄격히 규정하여 근로시간 유연화제도가 도입된 1997년 이후에도 여전히 포괄임금제 적용범위를 엄격하게 보지 않는 점은 비판되고 있다.⁸⁴⁾

법원이 현재의 판례법리보다 더 엄격하게 본다고 하더라도 포괄임금제와 근로시간유연화제도는 여전히 기능상 충돌된다. 예를 들어 근로시간 유연화제도의 요건을 갖춘 경우에만 포괄임금제가 허용되어야 한다고 해석하더라도 여전히 포괄임금제를 하는 것이 사용자에게는 더 유리한 면이 있다. 야간근로에서 보는 바와 같이 판례법리에서 허용되는 포괄임금제의 적용대상이 감시·단속적 근로에 대한 적용제외 조항의 적용범위보다 더 넓기 때문이다.

이제까지 대법원에서 포괄임금제가 문제가 된 사건들에서의 직업을 보면, 경비원, 버스운전기사, 해외건설현장 관리직, 공장 일용직 주부사원, 방송사 외부제작 요원, 식당 봉사 및 조리원, 환경미화원, 요양보호사, 건설일용직, 인턴 등이다. 이들은 통상의 근로시간 체제와 다르게 일하거나 혹은 고용형태가 통상적인 것과 다른 경우들이다. 그렇지만 이 사건들에서는 통상의 근로시간 체제나 고용형태가 다르다는 것에 대해 다툼이 있지는 않았다. 다른 근로시간 체제나 고용형태에서 추가로 일하는 시간만큼 임금을 지급받지 못했다고 주장하는 것에 대한 사용자의 항변사유로서 포괄임금제가 다투어진 것이다. 이러한 점을 감안하면 앞의 직업군의 근로자들에 포괄임금제가 허용된다고 하면, 이들은 근로시간제와 고용형태의 특성면에서 근로기준법상의 규제를 제대로 받지 못할 위험에 더해 자신들이 추가로 일한 시간만큼 보상을 받지 못할 위험이 추가되어 있다고 볼 수 있다. 이러한 점에서 포괄임금제는 통상적인 근로시간 유연화제도를 비껴가게 함으로서 근로기준법의 사각지대를 더욱 크게 만들고 있다. 이렇게 근로기준법의 사각지대가 더 커지게 되면 그러한 지대에서 근무하는 근로자들이 근로기준법에서 정하는 최소한도로 인간의 존엄성

84) 하갑래·최미나. 앞의 보고서, 114-115쪽.

을 보장받거나 인간다운 생활을 영위하지 못할 위험성이 더욱 커진다고 볼 수 있다.

2. 규제방안

1) 온존 및 확대

근로시간 유연화가 더욱 더 필요하다는 전제에서 포괄임금제를 바라보는 입장이 있다. 예를 들어 근로시간 유연화제도를 보완하는 역할을 수행하기 때문에 현재와 같은 포괄임금제가 유지되어야 한다는 견해가 있다.⁸⁵⁾ 또한 포괄임금제를 더 이상 근로기준법에 반하는 제도로 여기지 않도록 근로기준법 제63조의 개정을 통해 포괄임금제 적용대상을 제63조의 적용제외업무와 일치하도록 하자는 견해도 있다.⁸⁶⁾ 이 견해들은 공히 근로시간 유연화 제도의 확대·도입을 위해 미국의 사무직 적용제외제도나 일본의 기획업무형 재량근로제도 도입할 필요가 있다고 본다. 이 견해에는 포괄임금제의 부정적 기능을 최소화하는 내용이 거의 보이지 않는다. 이런 점에서 위 견해는 포괄임금제에 대한 규제안이라고 보기 힘들 것이다. 따라서 이하에서는 이 견해와 관련하여 별도로 논의하지 않는다.

2) 유지 및 개선

포괄임금제를 현재의 방식대로 운영하되 적절하게 개선해나가야 한다는 입장이 있다.⁸⁷⁾ 그 근거로 포괄임금제가 많은 사업장에서 널리 활용되고 있고, 다양한 업무형태로 인해 새로운 방식의 근로조건의 규율이 필요하고, 폐단의 여지가 있지만 제도 자체는 긍정적일 수 있다는 점을 들고 있다. 그래서 이 견해는 현행법의 테두리 내에서 오·남용의 여지

85) 이승길, “포괄임금제의 법리와 효용성에 관한 연구”, 『노동법논총』 제29호, 한국비교노동법학회, 2013, 233쪽.

86) 이경연, “포괄임금제에 관한 연구”, 『노동연구』 제27호, 고려대학교 노동문제연구소, 2014, 168-175쪽.

87) 정재현, 앞의 논문, 87쪽.

를 막는 것이 필요하다고 본다.⁸⁸⁾

앞서 해석론에서 본 바와 같이 판례법리 자체가 명확하지 않다. 또한 판례법리가 근로시간의 산정이 어려운 경우를 넓게 보고 있다. 그리고 무엇보다 판례법리는 포괄임금제에 대한 판단에서 근로시간 유연화제도와와의 관계를 면밀하게 고려하지 않고, 그 관계면에서 고려되어야 할 점을 전혀 받아들이고 있지 않다. 그렇기 때문에 이 견해는 포괄임금제의 오·남용의 여지를 막는 것이 필요하다고는 하지만, 현행 판례법리의 변화를 전제로 하지 않는 한, 포괄임금제의 규제에 대한 구체적이고 타당한 안이라고 보기 힘들다.

3) 입법적 제한

포괄임금제에 대해 일정한 한계를 설정하여 제한적으로 예외적으로 허용하자는 입장이 있다.⁸⁹⁾ 이 입장은 두 가지 방안을 제시하는데, 우선 연장근로와 휴일근로에 대해 포괄임금제에 포함시킬 수 있는 시간의 월간 및 연간한도를 정하는 것이다. 다음으로는 포괄임금제의 채택에 대해 근로자 본인의 명시적 동의와 더불어 근로자대표의 동의를 얻도록 하자는 것이다.

위 입장은 현행 근로시간 유연화제도와와의 관계를 분명히 밝히고 있지 않다. 만약 현행 근로시간 유연화제도를 유지한 채 위와 같은 내용의 입법이 이루어진다면, 또 하나의 유연화제도가 도입되게 된다. 새 유연화제도는 근로자 본인의 동의가 추가된다는 점에서 대부분 근로자대표와의 서면합의를 필요로 하는 기존의 유연화제도보다는 요건이 강화된다고 볼 수 있다. 그러나 기존의 다른 유연화제도와와의 관계에서 많은 문제를 낳을 수 있다. 근로시간의 적용제외 조항과는 충돌을 일으킬 수 있다. 근로시간의 산정이 어려운 경우는 적용제외조항 대상업무에 해당되는 경우가 많은데, 이렇게 대상 업무가 중복되나 그 요건은 다르면서도 또한 법적 효과는 유사해질 수 있는 여지가 있기 때문이다. 재량근로제와 관련해서

⁸⁸⁾ 정재현, 앞의 논문, 114쪽.

⁸⁹⁾ 강성태, “근로기준법상 임금제도의 개선방향에 관한 연구”, 『노동법연구』 제 10호, 서울대학교 노동법연구회, 2001, 182쪽.

도 유사한 문제가 발생할 수 있다.

위의 입장과 유사하게 포괄임금제를 입법적으로 제한하자는 다른 견해가 있다.⁹⁰⁾ 이 견해는 도입방식에 있어서는 다른 유연근로시간제와의 균형을 고려하여 근로자대표와의 서면합의를 통해서 하는 것을 제안한다.⁹¹⁾ 그렇지만 이 견해는 추가의 제한사항을 제시함으로써 위의 견해보다 더 구체적이고 체계적이다. 우선 포괄임금제는 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’로 한정하며, 다음으로 다른 근로시간 유연화 제도 즉 사업장 밖 간주근로시간제와 근로시간 적용제외, 재량근로제의 업무에 대해서는 포괄임금제를 허용하지 않게 하자는 것이다.⁹²⁾ 이렇게 함으로서 앞의 견해와 달리 이 견해는 기존 유연화제도와 충돌되지 않는다. 이 견해대로 하게 되면, 포괄임금제로 허용되는 업무는 현행 판례법리로 인정되거나 인정될 수 있는 것보다 훨씬 줄어들게 될 것이다. 우선 감시·단속적 근로는 제 63조 적용제외 대상업무이기 때문에 더 이상 포괄임금제가 허용되지 않는다. 재량근로제 업무도 현행 판례법리에서 인정될 가능성이 크나, 포괄임금제가 허용되지 않는다. 사업장 밖 근로의 경우도 마찬가지이다. 이렇게 되면 앞에서 논의되었던 업무 중에서는 도급제 근로 정도가 포괄임금제가 허용되게 될 것이다.

4) 입법적 금지

포괄임금제를 입법으로 금지하자는 첫 번째 견해⁹³⁾는 그 근거를 다음과 같이 든다. 이 견해에 따르면 포괄임금제는 우선 장시간 근로를 상대적으로 만들고, 인간의 생활형태에 맞지 않은 근로형태의 도입을 용이하게 만든다. 다음으로 포괄임금제는 근로기준법의 근로시간 제한의 규율을 부정한다. 이 견해는 이와 같은 포괄임금제가 판례를 통해 법리로서 허용되는 것이 고착되었기 때문에 입법으로 금지할 필요가 있다고 주장한다.

90) 하갑래·최미나, 앞의 보고서.

91) 하갑래·최미나, 앞의 보고서, 137쪽.

92) 하갑래·최미나, 앞의 보고서, 131-134쪽.

93) 하갑래, 앞의 논문, 357쪽; 김홍영, 앞의 논문, 858쪽.

이 견해에 대해 근로시간제도가 경직적이어서 포괄임금제는 ‘시장의 자율적인 우회로’⁹⁴⁾인데 금지시키는 것은 타당하지 않다는 비판이 있을 수 있다. 이에 대해 이 견해는 유연성을 부여하는 방안도 판례법리보다 유연적 근로시간제도의 개정을 통해 이루어져야 법적인 안정성이 있다고 반박한다.⁹⁵⁾ 그러한데도 판례법리가 근로시간 유연화제도와 별개로 포괄임금제를 허용함에 따라 근로기준법상의 유연화제도의 기능이 약화된다고 이 견해는 본다. 더 나아가 이 견해는 근로기준법상 유연화제도가 시행되어 그 결과로 포괄임금제와 유사한 효과가 발생한다고 하더라도 이것은 유연화제도 자체의 효과이어서 포괄임금제에 의한 설명이 필요하지 않다고 본다.

포괄임금제를 금지하는 입법을 제안하는 두 번째 견해⁹⁶⁾는 앞서 언급한 바 있는 근로시간법의 규율체계에서 포괄임금제가 갖는 문제점을 강조하면서 포괄임금제를 폐지하는 입법을 제안한다. 다만 이 견해는 첫 번째 견해와는 달리 포괄임금제가 금지됨과 동시에 현행 근로시간유연화제도가 보완되어야 하는 점을 지적한다. 이 견해는 대상적인 조치 없이 금지되는 사항과 대상적인 조치를 하면서 흡수되는 사항으로 구별하여 구체적인 입법안을 제안한다. ‘계산의 편의를 위한 포괄임금제’는 전자에 해당한다. 후자로는 예를 들어 탄력적 근로시간제에서는 단위기간 확대가 필요할 수 있고, 선택적 근로시간제에서는 의무근로시간대 미설정시 야간·휴일근로수당 적용제외를 명시할 수 있고, 사업장 밖 간주근로시간제에서는 야간·휴일근로에도 간주제가 적용됨을 명시하고, 재량간주근로시간제에서는 전문업무형 대상 업무를 확대하고 기획업무형을 신설하는 것을 고려하고, 근로시간 적용 제외와 관련해서는 휴일근로수당을 제외하고 관리감독적 업무에 대한 판단기준을 정비하는 것을 제안한다.⁹⁷⁾

더 나아가 위 첫 번째 견해와 두 번째 견해 모두 포괄임금제의 금지를 내용으로 하여 근로기준법 제56조의 개정을 제안한다. 그 개정 내용은

94) 강성태, 앞의 논문, 270쪽.

95) 김홍영, 앞의 논문, 859쪽.

96) 하갑래·최미나, 앞의 보고서.

97) 하갑래·최미나, 앞의 보고서, 129쪽.

‘임금 및 가산임금을 해당 근로시간에 따라 계산하여 각각의 임금항목별로 명시하여 지급하여야 하며, 각각의 임금항목이 다른 임금항목에 포함되어 있는 것으로 간주하거나 해당 근로시간과 관계없이 일정한 금액을 지급할 수 없다’고 하거나,⁹⁸⁾ ‘임금을 총임금이나 정액수당에 미리 포함하여 산정하여서는 아니 된다’고 하거나 ‘근로시간 수 및 임금의 액수를 특정하여야 한다’고⁹⁹⁾ 규정한다. 더 나아가 그 내용에는 포괄임금제에 의해 지급되는 정액수당이 가산하여 지급한 임금보다 많은 경우 예외적으로 허용하는 단서조항의 추가할 것을 제안한다.¹⁰⁰⁾

위의 개정안과 유사하게 제56조의 개정으로 포괄임금제를 금지하는 내용을 포함한 근로기준법 개정안¹⁰¹⁾이 2012년 제출된 바 있다. 그리고 포괄임금제를 금지하면서도 제56조가 아닌 제17조의 개정을 제안하는 개정안¹⁰²⁾이 2017년 3월 국회에 제출되어 있다. 제17조의 명시사무의 개정을 통해 금지할 경우 그 계약의 효력에 대한 다툼이 있을 수 있다는 지적이 있다.¹⁰³⁾ 현재 제출된 개정안은 포괄임금제 계약을 체결하는 경우 그 계약을 무효로 하고 근로기준법에 따른다고 하여 이러한 다툼의 여지를 없애고 있다.

5) 소결

포괄임금제에 관한 판례법리가 변화되는 것을 전제로 하면, 포괄임금제를 제한하거나 금지하는 입법까지는 필요하지 않다고 할 수도 있다. 그러나 판례법리가 포괄임금제에 대해 현재보다 더 엄격하게 성립여부와 유효성을 판단할 것이라고 기대하기는 힘들다. 더구나 1997년 근로시간 유연화제도가 도입된 이후에도 이를 전혀 고려하지 않고, 포괄임금제에 대한 판례법리가 현재와 같은 형태로 발전해 온 점을 감안하면 더욱 그

98) 하갑래·최미란, 앞의 보고서, 121쪽.

99) 김홍영, 앞의 논문, 860쪽.

100) 김홍영, 앞의 논문, 861쪽.

101) 한정애의원 대표발의, 근로기준법 일부개정법률안, 의안번호 546, 2012.7.6.

102) 이정미의원 대표발의, 근로기준법 일부개정법률안, 의안번호 6004, 2017.3.6.

103) 김홍영, 앞의 논문, 860쪽.

렇다. 설령 판례법리가 이러한 방식으로 변화된다고 하더라도 판례법리는 오랜 시간에 걸쳐 축적되어 왔고, 개별 사건이 발생하였을 때 이를 판단하는 방식이기 때문에 판례법리가 일시에 더 엄격하게 바뀌는 것은 기대하기 어렵다. 그러한 점 때문에 판례법리가 근로기준법 규율체계의 예외로서 인정해왔던 포괄임금제를 명시적으로 제한하거나 금지하는 입법이 포괄임금제의 규제방안으로서는 더 적절하다.

포괄임금제를 제한하거나 금지하는 입법이라고 하더라도 다른 근로시간 유연화 제도나 조항과 독립적으로 포괄임금제의 요건을 규정하는 방안은 내용상 포괄임금제가 다른 근로시간 유연화 제도나 조항과 중복되기 때문에 현실적으로는 타당한 방안이라고 볼 수 없다. 포괄임금제 규제의 입법안은 제58조와 제63조와 그 규율대상이 중복되는 점을 해결하여야 한다. 제시된 입법안 중에서는 제58조와 제63조의 적용대상 업무이외의 업무에만 포괄임금제를 허용하거나, 포괄임금제 자체를 금지하는 것으로 이러한 문제를 해결하고 있다.

전자의 입법안이 포괄임금제를 제한적이거나 허용하는 것이고, 후자의 입법안이 완전히 금지하는 것이어서 전자와 후자의 입법안이 차이가 클 것이라고 생각될 수 있다. 그러나 실제로의 차이는 그렇게 크지 않을 것으로 보인다. 앞서 언급한 바와 같이 전자의 입법안에서 제58조와 제63조의 대상업무가 포괄임금제 허용대상에서 배제되기 때문에 이 업무들을 제외하면 새로운 입법안에서 허용되는 포괄임금제 업무의 범위는 극히 협소해진다. 반면에 후자의 입법안에서 포괄임금제를 금지한다고 하더라도 논리적인 면에서 근로시간의 산정이 불가능하거나 무의미한 경우는 근로기준법 등에 위반된다는 점을 입증하기가 불가능하기 때문에 차액의 임금청구 등이 가능하지가 않다. 따라서 완전히 포괄임금제를 금지하는 입법이라고 하더라도 실질적으로는 포괄임금제가 허용되는 경우가 극히 드물더라도 존재할 수 있을 것이다.

사건으로는 포괄임금제를 제한적으로 허용하는 입법안보다 포괄임금제를 금지하는 입법안에 찬성한다. 전자의 입법안은 제58조와 제63조의 대상업무를 제외하면 포괄임금제의 범위에서 제외한다면 포괄임금제를 금지하는 안이 큰 차이가 없음에도 불구하고, 입법 형식상으로는 포괄임금

제를 허용하는 것이어서 적절하지 않아 보인다. 반면에 후자의 입법안은 근로기준법상 근로시간 산정의 원칙을 분명히 한다는 점에서 더 타당하다. 다만 근로시간의 산정이 불가능하거나 무의미한 경우는 예외로 하는 규정을 단서로 추가할 수도 있을 것이다. 또한 실제의 근로시간수를 산정하여 계산한 가산임금이상의 임금을 지급하는 것을 전제로 하여 계산의 편의를 위해 포괄임금제를 실시하는 것도 예외적으로 허용될 수 있을 것이다.

IV. 결론

이 글에서는 포괄임금제에 관한 해석론의 쟁점에 대해서는 판례법리와 학설을, 그리고 입법론상의 쟁점에 대해서는 학설을 검토하였다. 먼저 해석론상의 쟁점은 최근의 대법원 판결에 따라 명확해진 판례법리의 판단 구도에 따라 포괄임금제의 성립여부와 유효성을 순서에 따라 살펴보았다. 최근의 대법원 판결들은 포괄임금제 약정이 성립되었는지에 대해 이전보다 더 엄격하게 판단하여 포괄임금제의 성립을 인정하지 않고 있음을 확인하였다. 더 나아가 대법원은 포괄임금제가 성립하였다고 하더라도 근로시간의 산정이 어려운 경우로서 실제의 근로시간수에 따라 산정된 가산임금액보다 포괄임금제로 지급하는 수당액이 더 적다면 유효하지 않은 것임을 명확히 하여 유효성 판단에 있어서도 엄격해지고 있다. 명시적으로 부정하지는 않았지만 일련의 대법원 판결들은 계산의 편의 등을 위해 실시된 포괄임금제에 대해 실제 근로시간수에 따른 임금과의 비교 없이 유효성을 인정했던 과거의 대법원 판결들은 더 이상 유지될 수 없다는 점을 이 글은 확인하였다.

그렇지만 최근의 대법원 판례법리는 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’가 어떠한 것인지에 대해서는 구체적이고 일관적인 기준을 제시한 바가 없다. 이 글은 현행 판례법리가 포괄임금제가 허용되는 요건으로 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’를 ‘근로시간의 산정이 불가능하거나 무의미한 경우’로 엄격하게 해석하고, 근로기준법상 근로시간 유연화대상업무(사업

장 밖 근로, 재량근로제, 근로시간적용제외 업무)에 대해서는 포괄임금제가 허용되지 않도록 해석해야 한다고 주장한다. 판례법리가 감시단속적 근로의 예에서 보는 바와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우에 근로시간의 산정이 불가능하거나 무의미한 경우뿐만 아니라 실제로 근로시간 산정이 가능한 경우를 포함한 것은 비판적으로 본다. 제63조의 근로시간 적용제외제도와 제58조의 근로시간 유연화 제도는 근로시간 산정이 어려운 경우 등을 포함하여 근로시간의 산정에 의한 임금의 지급이라는 근로기준법의 원칙을 배제하는 것이어서 이와 중복적으로 혹은 확대하여 포괄임금제를 허용하는 것은 제58조와 제63조의 도입취지에 어긋난다. 따라서 이들 조항의 도입취지를 감안하여 제58조와 제63조의 대상업무를 포괄임금제 업무에서 제외하면, 근로시간의 산정이 어려운 경우는 산정이 불가능하거나 무의미한 경우로 한정될 수밖에 없는 것이다.

구체적인 근로형태별로 보면, 우선 판례법리는 감시·단속적 근로에 대해 제63조의 적용제외 요건인 고용노동부의 승인을 받지 않았더라도 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’로 본다. 아직까지 적용된 사례는 없지만 판례법리는 제58조 제3항의 재량근로제 대상 업무에 대해서도 제58조 제3항의 적용요건을 충족했는지에 관계없이 근로시간의 산정이 어려운 경우로 볼 가능성이 크다. 재량근로제나 근로시간적용제외의 대상업무에 대하여 해당 조항의 요건을 갖추지 않았는데도 근로시간의 산정이 어려운 경우로 봄에 따라, 사용자는 상대적으로 요건상 더 쉽게 성립하는 포괄임금제를 선호하게 되어, 제58조나 제63조가 무력화되는 결과가 초래된다. 이러한 문제는 최근의 판례법리조차 근로시간 적용제외제도, 그리고 1997년에 도입된 제58조의 근로시간 유연화 제도의 취지를 반영하지 않고, 포괄임금제 판례법리를 형성한 것에 기인한다. 이 글은 더 나아가 포괄임금제가 만연하다고 알려진 일반 사무직의 경우는 현행 판례법리에 의해서도 근로시간의 산정이 어려운 경우로 볼 수 없다고 본다. 그렇지만 도급제 근로의 경우에는 임금액수가 업적이나 성과물에 전적으로 연동되는 이상 현행 판례법리를 강화한다고 하더라도 근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당함을 확인하였다.

포괄임금제의 규제에 대해서 이 글은 일반 사무직군의 장시간 근로의

문제에 대한 해결 방안으로서는 포괄임금제를 제한하거나 금지하는 입법이 반드시 필요하지 않는다고 주장한다. 현행 관례법리에 의해서도 일반 사무직군은 근로시간의 산정이 가능한 경우로 보이며, 따라서 출퇴근 기록 관리나 입증책임의 강화 등의 보완조치만이 필요할 뿐이라고 이 글은 판단한다. 오히려 포괄임금제의 제한이나 금지의 입법 필요성은 오히려 포괄임금제로 인한 근로시간 규율체계의 무력화와 그에 따른 근로기준법 사각지대의 확대에 있다고 이 글은 주장한다. 더 나아가 이 글은 이러한 문제를 해결하기 위해서는 포괄임금제를 금지하는 입법이 더욱 타당하다고 주장한다. 이러한 주장은 새로운 입법에 의해서도 여전히 근로시간의 산정이 불가능하거나 무의미한 경우는 규제되기 힘들다는 점을 전제로 하고, 근로형태나 방식의 독특성 때문에 현재의 근로시간 유연화제도가 불충분하다면 이는 이 제도를 개선하는 문제로 논의가 필요할 뿐이라는 점을 근거로 하였다.

이 글의 대상은 아니지만, 최근 근로시간의 적용제외제도와 제58조의 사업장 밖 간주근로시간제와 재량근로제 자체에 대한 입법적 개선논의가 이루어지고 있다.¹⁰⁴⁾ 향후 이 제도들에 대해서도 그 자체적으로 면밀한 검토가 필요할 것이다. 그렇지만 이미 확인한 바와 같이 포괄임금제의 해석론과 입법론은 제58조와 제63조의 해석과 입법적 개선논의와 긴밀하게 연결되어 있다. 따라서 포괄임금제의 규제논의는 제58조와 제63조의 입법적 개선논의와 함께 수행되는 것이 바람직하고, 그 과정에서 양자의 상호관계가 분명히 정립될 필요가 있을 것이다. 향후 포괄임금제에 대한 논의에서는 이러한 부분을 집중적으로 검토할 필요가 있을 것이다.

주제어: 포괄임금제, 근로시간 적용제외, 재량근로, 간주근로시간제, 가산임금

104) 이에 대한 최근의 글로는 박지순, “근로기준법상 근로시간 특례조항의 법적 쟁점”, 한국노동법학회·노동법이론실무학회, 『임금 및 근로시간법제의 쟁점과 과제』, 공동학술대회 자료집 참조. 2017년 9월 23일 참조.

참고문헌

- 강선희, “포괄임금제의 성립 및 유효성 판단기준, 『노동법포럼』 제10호, 노동법이론실무학회, 2013.
- 강선희, “인턴(전공의)의 포괄임금계약 성립 및 유효성 여부-대전고등법원 2014.11.26. 선고 2013나11186 판결-”, 『월간노동리뷰』 2015년 1월호.
- 강선희, “간주근로시간제를 채택하고 있는 사업장에서의 포괄임금제의 유효성 및 최저임금 미달 여부-울산지방법원 2015.3.26. 선고 2013가합8607 판결-”, 『월간노동리뷰』 2015년 6월호.
- 강성태, “근로기준법상 임금제도의 개선방향에 관한 연구”, 『노동법연구』 제10호, 서울대학교 노동법연구회, 2001.
- 강성태, “포괄임금제 성립여부의 판단기준 및 노사합의에 의한 통상임금 변경의 효력”, 『노동법학』 제33호, 2010.
- 구미영, “감시단속직의 경우 포괄임금산정 성립 여부 판단-대구지방법원 2013.7.11. 선고 2012나25553판결”, 『노동법학』 제48호, 2013.
- 국정기획자문위원회, “문재인정부 국정운영 5개년 계획”, 2017년 7월.
- 김기선, “포괄임금제에 관한 법률적 쟁점 및 개선방안”, 정동관·이경희·정경은·최미나·김훈·김기선, 『사무직 근로시간 실태와 포괄임금제 개선방안』, 한국노동연구원, 2016. 제6장.
- 김기선·강성태·조용만·한인상·정영훈·노호창·김근주, 『근로시간법제 주요 쟁점의 합리적 개편방안』, 한국노동연구원, 2015.
- 김유선, “노동시간 실태와 단축 방안”, KLSI Issue Paper 제2호, 한국노동사회연구소, 2017.
- 김지형, “노동쟁송과 판례연구(하)”, 『인권과 정의』 제319호, 대한변호사협회, 2003.
- 김진석, “포괄임금계약의 허용범위 - 대상판결: 대법원 2010.5.13. 선고 2008다6052 판결-”, 『노동법실무연구』 제1권, 노동법실무연구회, 2011.
- 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 『성균관법학』 제23권 제3호, 2012.
- 김홍영, “포괄임금산정의 성립 판단-대법원 2016.10.13. 선고 2016도1060 판결-”, 『월간노동리뷰』 2017년 2월호.
- 김희성, “근로시간제도에 관한 연구(2): 유연한 근로시간제도와 관련하여”, KERI Insight 16-23.
- 노동법실무연구회, 『근로기준법주해III』, 박영사, 2010.

- 박순영, “근로기준법상 근로시간의 규제와 포괄임금제”, 『대법원판례해설』 제83호, 법원도서관, 2010.
- 박지순, “근로기준법상 근로시간 특례조항의 법적 쟁점”, 한국노동법학회·노동법이론실무학회, 『임금 및 근로시간법제의 쟁점과 과제』, 2017년 9월 23일 공동학술대회 자료집.
- 배규식, “한국 장시간 노동체제의 지속요인”, 『경제와 사회』 95호, 2012.
- 배규식, “근로시간의 정의, 측정, 산정과 보상”, 『월간노동리뷰』 2012년 3월호.
- 배규식·조성재·홍민기·김기민·전인·이영호·권현지·진숙경·이문범, 『장시간 노동과 노동시간 단축(I)-장시간 노동 실태와 과제』, 한국노동연구원 연구보고서, 2011.
- 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 『인권과 정의』 제347호, 대한변호사협회, 2005.
- 신수길, “포괄임금제에 의한 임금지급계약이 유효하기 위한 요건”, 『대법원판례해설』 제32호, 1999.
- 양승엽, “근로시간이 산정가능한 경우의 포괄임금제 인정 요건- 대법원 2016.9.28. 선고 2014다56652 판결-”, 『월간노동리뷰』 2016년 12월호.
- 이경연, “포괄임금제에 관한 연구”, 『노동연구』 제27호, 고려대학교 노동문제연구소, 2014.
- 이광선, “포괄임금 약정의 효력과 문제점-대판 2010.5.13., 2008다6052를 중심으로”, 『저스티스』 한국법학원 2014.
- 이국환, “감시단속적 근로와 포괄임금계약의 유효성”, 『대법원판례해설』 제28호, 법원도서관 1997.
- 이병한, “포괄임금제의 성립 여부를 판단하는 기준”, 『대법원판례해설』 제81호, 법원도서관, 2010.
- 이승길, “포괄임금제의 법리와 효용성에 관한 연구”, 『노동법논총』 제29호, 한국비교노동법학회, 2013.
- 이재용, “근로시간의 산정이 어려운 사정이 없는 경우 포괄임금계약의 효력 : 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결을 중심으로”, 『법학연구』 제43호, 2011.
- 임중률, 『노동법』, 박영사, 2017.
- 전윤구, “가산수당을 합산한 포괄임금제의 효력요건”, 『조정과 심판』 제43호, 중앙노동위원회, 2011.
- 정재현, “포괄임금제의 재조명”, 『사법』 제15호, 사법발전재단, 2011.

- 최석환, “근로계약 과정에서 나타나는 당사자 합의의 해석”, 『노동법연구』 제41호, 서울대학교 노동법연구회, 2016.
- 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 『노동법학』 제29호, 한국노동법학회, 2009.
- 하갑래, “사무직 관련 근로자의 근로시간제도에 관한 연구”, 『법학논총』 제39권 제1호, 2015.
- 하갑래·최미나, 『포괄임금제의 운영실태 및 개선방안에 관한 연구』 고용노동부 학술연구용역보고서, 2012.
- 한국노동연구원, 『장시간 노동실태와 노동시간 단축 토론회』 자료집, 2012.

<Abstract>

Blanket Wage System: Issues and Prospect 2017

Shim, Jae-jin^{*}

This article looks at the Blanket Wage System(BWS) at the time when the new Government has announced a proposal to restrict the BWS. It aims to make clear the interpretational issues in relation to the BWS and review proposals for legislative changes for the restriction or prohibition of the BWS.

To begin with, the article overviews the court cases concerning the BWS over the last several decades. It finds that the rulings of the Supreme Court have been clearer since 2009. In 2009, the Court held that agreements for the BWS have not to be admitted as real ones for the BWS when clauses in employment contracts, work rules or collective agreements provide that each of overtime payments is to be paid separately. In 2010, furthermore, the Court held that the real agreements for the BWS is not valid when payments based on actual working time are less than payments on the BWS.

The article criticizes such rulings while it welcomes changes to more strict and clearer regulation for the BWS. It do so for the reason that the Court does not indicate clearly the meaning of the occasion where working time is difficult to grasp. If the occasion takes place, according to the court rulings, the BWS is allowed to be maid. Moreover it maintains that the BWS has to be regarded as valid only when working time is impossible or meaningless to grasp.

Lastly, the article proposes certain directions on legislative regulation

^{*} Professor, Sogang Law School.

in relation to the BWS. Such regulation, it suggests, is necessary to introduce not because the BWS has been one of the reasons that most workers have to work long hours but because workers in certain areas are badly treated because of the BWS. The former can be successfully tackled by strengthening enforcement of labour law according to the rulings of the Court above without legislative changes.

Key Words: Blanket Wage System, working hours, overtime payments, flexible working hours